

1500954-81.2022.8.26.0266

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... que para o perdimento de bem apreendido em decorrência do tráfico de drogas, não é necessário que ele tenha sido adaptado para o cometimento do crime.

Segundo o Tema 647 do STF, "é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Foro de Itanhaém

1ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, Itanhaém-SP - cep 11740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500954-81.2022.8.26.0266 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 05/09/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500954-81.2022.8.26.0266

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANIZIO GOMES DE MACEDO NETO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS...

ROBERT DE SOUZA SILVA e ANÍZIO GOMES DE MACEDO NETO, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos delituosos narrados na introital de fls. 01/03, a saber:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 21 de junho de 2022, por volta das 20h, na avenida Julinha, bairro Califórnia, Itanhaém, ROBERT DE SOUZA SILVA e ANÍZIO GOMES DE MACEDO NETO, qualificado nos autos, agindo em unidade de desígnios, transportaram, para fins de entrega a terceiras pessoas, 20 (vinte) tijolos prensados de Cannabis sativa L e 01 (uma) porção a granel de cocaína, drogas que causam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização legal e regulamentar. É dos autos que os denunciados, oriundos do município de Santo André/SP, seguiam no automóvel VW/Gol, placas CKC-6417, cor vermelha, conduzido por

ROBERT, e no qual ANÍZIO seguia no banco do passageiro, oportunidade em que, em unidade de desígnios transportavam 20 tijolos de prensados de maconha e uma porção a granel de cocaína, visando a entregá-las a pessoas desconhecidas, neste município de Itanhaém. Ocorre que, após demonstrarem certo nervosismo em razão da aproximação de uma viatura da polícia militar, os denunciados obedeceram à ordem de parada, tendo os milicianos encontrado asdrogas dentro de uma caixa de papelão, no interior do veículo, no qual também seguia, no banco de passageiro, o filho do denunciado ANÍZIO, uma criança de 06 anos de idade.”

Acompanhou a denúncia o auto de prisão em flagrante, no qual, estando em termos, foram juntados, dentre vários outros documentos, termos de declarações, o boletim de ocorrência (fls. 10/15), o auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), o auto de constatação prévia de entorpecente (fls. 19/20), as notas de culpa (fl. 27- Robert e fl. 35- Anízio), o laudo toxicológico (fls. 181/183) e o relatório lavrado pela Polícia Judiciária (fls. 184/186).

Por ocasião da audiência de custódia, as prisões em flagrante de Robert e Anízio foram convertidas em preventiva, com esteio no art. 312 do Código de Processo Penal, por entendê-las necessárias à garantia da ordem pública (fls. 107/110). Mandados de prisão expedidos às fls. 116/119, devidamente cumpridos às fls. 142/145 e 146/147 respectivamente.

Às fls. 111/112, porquanto preenchidos os requisitos legais, a denúncia desfechada foi recebida, determinando-se, na sequência, a citação dos acusados na forma do artigo 396 do Código de Processo Penal, c/c art. 55 da Lei n. 11.343/2006. Citados, a resposta escrita foi devidamente colacionada às fls. 156/163, por intermédio de defensora constituída. Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 176/178).

Na solenidade, iniciados os trabalhos, foram inquiridas as testemunhas arroladas em comum, Alexandre, Moizes, bem como aquelas arroladas exclusivamente pela defesa, Alisson, João, Beatriz, Vanessa e Flávio, sendo os réus interrogados ao final. Em sede de debates orais, a acusação protestou pela integral procedência da denúncia.

A defesa, por seu turno, propugnou pela realização de diligência complementar, o que foi deferido. Cumprido o quanto determinado e, devidamente intimada, ofereceu memoriais, sede em que requereu a absolvição dos acusados, sob a égide da anemia de provas (fls. 357/371).

É o breve relato dos autos (artigo 381, incisos I e II, do Código de Processo Penal). FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal manejada pelo Ministério Público com o fito de obter a condenação dos acusados Robert de Souza Silva e Anízio Gomes de Macedo Neto nas sanções do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A materialidade da narcotraficância encontra-se sobejamente evidenciada por intermédio do auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), auto de constatação prévia de entorpecente (fls. 18/19) e, principalmente, por meio do laudo toxicológico de fls. 181/183 oportunidade em que concluíram os experts tratarem-se as substâncias apreendidas de 1.8471,8g de Tetrahydrocannabinol e 874,6g de Cocaína. A autoria dos acusados, da mesma forma, malgrado o louvável esforço da defesa, ressuma igualmente caracterizada pela prova testemunhal produzida.

Quando de seu interrogatório realizado em solo policial, o acusado Robert (fl. 07) esclareceu que na data dos fatos recebeu o convite de transportar uma encomenda até o Guarujá, mediante a contrapartida de R\$600,00 pelo serviço e, como lidava com dificuldades financeiras, aceitou-o. Para tanto, chamou o amigo Anízio para acompanhá-lo na viagem, o qual, por seu turno, levou o filho, de nome Benjamin. Ao

chegar ao Guarujá foi carregada em seu carro (Gol, placa CKC-6417) uma outra caixa, recebendo a orientação de transportá-la até Itanhaém. Ao chegar nesta cidade foi abordado pela Polícia Militar, átimo em que encontradas drogas na caixa alvitrada.

Em Juízo, afirmou que saiu mais cedo do trabalho no dia dos fatos. Enquanto lavava seu carro encontrou Anízio, o qual estava acompanhado de seu filho e o convidou para irem para Itanhaém buscar uma máquina caça-níquel, a pedido de Geovani. Este, por seu turno, além de repedir a oferta, disse que lhes pagaria o combustível e prometera o valor de R\$ 500,00 após a execução da entrega. Em Itanhaém, no endereço indicado, um Sandero prata se aproximou e seus tripulantes desembarcaram e colocaram uma caixa de papelão grande no bagageiro do carro dos acusados. Após a transição da mercadoria, que acreditava ser uma máquina caça-níquel, após convergirem para próxima rua, foram abordados e presos pelos policiais militares. Desconhecia a origem do objeto transportado, tendo sido ludibriado por Geovani. Confessou os fatos em solo policial por ter sofrido pressão psicológica pelos policiais militares. Não sabia que poderia relatar os abusos ocorridos na audiência de custódia, optando em relatar o ocorrido na presente solenidade.

Já Anízio (fl. 08), ao ser interrogado pela autoridade policial, relatou que Robert, seu amigo, convidou-o para irem até o Guarujá, o que aceitou. Naquela cidade, em local impreciso, foi carregada uma caixa de papelão de conteúdo desconhecido no veículo por si tripulado. Salientou que Robert receberia R\$600,00 pelo transporte da encomenda, cifra esta que seria dividida entre os dois. Esclareceu, por fim, que Robert foi incumbido de transportar a caixa até um local que desconhece, na cidade de Itanhaém.

Na presente solenidade, outorgou aos fatos nova versão. Disse ter sido contratado por Geovani para buscar uma máquina caça-níquel em Itanhaém. Como não tinha nenhum veículo para tanto, convidou Robert para a empreitada, o que foi aceitou. Levou seu filho, Benjamin, para aproveitar o passeio a fim de apresentar-lhe a praia. Valeram-se do carro de Robert para a viagem. Embora tivessem o nome da rua para onde deveriam se deslocar, não tinham o número da casa. Ao chegarem nesta comarca, foram interpelados por um carro, quando adentraram na rua combinada. Uma caixa foi colocada no porta-malas do veículo gol. Logo na sequência foram abordados por policiais militares, átimo em que encontrado o estupefaciente no veículo, o que ignorava. Não leu o que assinou em solo policial, rechaçando, portanto, a versão veiculada em seu interrogatório indiciário e lida a si por este Juízo.

Todavia, quando confrontadas as versões externadas pelos acusados com as demais provas produzidas, desfalecem ante sua fragilidade, evidenciando, sobremaneira, tratarem-se de subterfúgios lançados para elidirem os rigores da lei penal.

O Policial Militar Alexandre, em seu depoimento prestado na etapa indiciária (fl. 04), asseverou que na data dos fatos estava em serviço, juntamente com o Cb/PM Moizes e com o motorista Barros, em patrulhamento preventivo e ostensivo pelo bairro Jardim Botiporanga, nesta cidade, com o intuito de coibir a prática de crimes contra o patrimônio. Em um dado momento, enquanto estavam pela Avenida Julinha, teve sua atenção voltada para o veículo VW/Gol, vermelho, placas CKC-6417, tripulado por suas pessoas. Estes, ao perceberem a aproximação da viatura, demonstraram nervosismo, o que lhe incutiu a suspeita de que estariam transportando algo ilícito. Atendida, prontamente, a ordem de parada pelos réus, constatou a presença de uma criança no banco traseiro, Benjamin Figueiredo Macedo, de seis anos. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o inculpadados. E, vistoriado o automóvel, encontrou 20 tijolos aparentemente da droga conhecida por maconha e 1 porção a granel da droga que aparentava ser cocaína. Indagados, os réus informaram ser de Santo André e que teriam recebido o convite de transportarem certa quantia de drogas do Guarujá até Itanhaém.

Estes, em linhas gerais, foram os mesmos fatos articulados pelo Policial Militar

Moizes, em seu depoimento prestado em solo policial (fl. 06) e em Juízo. Sob o crivo do contraditório, ainda enfatizou que ambos os acusados revelaram, quando abordados, a existência de estupefacientes no porta-malas do veículo.

É cediço que o valor do depoimento policial, inexistindo má-fé, constitui importante elemento de prova, o qual merece confiança, pois realizado após compromisso e sem contradita da parte do réu. Aliás, sobre a validade dos depoimentos dos policiais, relembre-se que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

Em outras palavras, segundo os milicianos, em diligências pelo local dos fatos, avistaram os acusados em atividade suspeita. Ao abordá-los, lograram encontrar expressiva quantidade de entorpecentes.

Outras provas foram produzidas. As testemunhas Alisson Evangelista de Souza, Vanessa Ferreira da Silva e Flávio Cezario do Carmo, arroladas pela defesa, ouvidas na presente oportunidade, somente teceram comentários sobre aspectos favoráveis à conduta social de Robert. Ficaram surpresos com a notícia de que foram presos por estes autos.

Já Beatriz Souza de Oliveira, companheira de Robert, ouvida na qualidade de informante, salientou que seu companheiro fora convidado por Anízio para transportar uma máquina de caça-níquel, não sabendo se o eletrônico se encontrava, ou não, no porta-malas do veículo. O informante João Victor Villar de Souza, primo de Robert, disse que seu parente somente lhe disse que estava indo na fatídica data, com Anízio, buscar uma máquina caça-níquel em Itanhaém, não sabendo quem os contratou.

Estas são as provas. Diferentemente do que pretende fazer crer a defesa, entendo assistir razão à acusação na imputação que é feita aos acusados. Isso porque, conforme narrado de forma pormenorizada pelas testemunhas, os réus transportavam expressiva quantidade de drogas no interior do veículo apreendido.

Vale dizer, conforme haure dos autos, os acusados, oriundos do município de Santo André/SP, seguiam no automóvel VW/Gol, placas CKC-6417, cor vermelha, conduzido por Robert, e no qual Anízio seguia no banco do passageiro. Ocorre que, após demonstrarem certo nervosismo em razão da aproximação de uma viatura da polícia militar, os réus obedeceram à ordem de parada, tendo os milicianos encontrado 20 tijolos de prensados de maconha e uma porção a granel de cocaína.

A alegação externada pelos acusados, no sentido de que desconheciam a existência da droga, convenhamos, soa, no mínimo, pueril. É caso de se aplicar à espécie a teoria da "cegueira deliberada", própria para as hipóteses em que o agente tem consciência da possível origem ilícita dos bens por ele ocultados ou dissimulados, mas, mesmo assim, deliberadamente cria mecanismos que o impedem de aperfeiçoar sua representação acerca dos fatos.

Por força dessa teoria, aquele que renuncia a adquirir um conhecimento hábil a subsidiar a imputação dolosa de um crime responde por ele como se tivesse tal

conhecimento. Ora, decerto que o indivíduo que recebe quantia para transportar uma caixa de uma cidade a outra, durante o período noturno, tem condições de perceber a ilicitude das substâncias que nela existem.

Outros aspectos ainda revelam a inequívoca certeza dos réus acerca do estupefaciente encontrado. A uma porque Geovani, o suposto contratante dos serviços, não foi arrolado pela defesa para secundar a alegação de que o transporte efetivamente seria de uma máquina caça-níquel. A duas porquanto as versões apresentadas apresentam-se nitidamente dispares daqueles externadas em solo policial. A este respeito, vale a observação de que, embora tenha o réu Robert alegado ter sido agredido pelos milicianos, razão esta de sua confissão policial, silenciou em Juízo, quando a audiência de custódia, embora presidido o ato por este Magistrado. Mais não é preciso dizer para se deflagrar a autoria do réu sobre os fatos.

De resto, a vasta quantidade de droga encontrada (18471,8g de Tetrahydrocannabinol e 876,6g de Cocaína), bem como as circunstâncias que envolveram o caso (apreensão de veículo utilizado para o transporte de drogas, além da confissão referida pelos policiais), transparecem a finalidade comercial própria do tipo penal

Todo o contexto da situação flagrancial não deixa dúvidas acerca da conduta ilícita cometida pelos acusados. De resto, não se podem imaginar razões que justifiquem a alegação de estarem os policiais a acusar um desconhecido da prática de um delito, quando isso não ocorreu, unicamente para atender a algum sentimento íntimo sádico de culpar terceiros. Veja-se que os depoimentos se mostraram harmônicos, sendo, ainda, secundados pela apreensão de entorpecentes (tetrahydrocannabinol e cocaína).

Diga-se de passagem, oportuno lembrar que:

“o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

E ainda:

“considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.” (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004).

Em resumo, encontram-se, pois, os acusados como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

DA PERDA DOS BENS:

Pela legislação em vigor, são três os tipos de bens que podem ser apreendidos: a) produtos do crime (artigo 60): vantagem direta obtida com a prática criminosa. Ex: o dinheiro recebido com a venda da droga; b) proveito auferido (artigo 60): é a vantagem indireta, conseguida a partir do produto, v.g., um carro comprado com a venda da droga; c) veículos, embarcações, aeronaves, maquinários, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática de crimes previstos na Lei (artigo 62).

O Supremo Tribunal de Federal, aliás, decidiu com repercussão geral, relativa ao Recurso Extraordinário 638.491, consagrando o Tema repetitivo 647 – STF, no sentido de que para o perdimento de bem apreendido em decorrência do tráfico de drogas, não é necessário que ele tenha sido adaptado para o cometimento do crime.

Segundo o Tema 647 do STF, "é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal."

Pois bem, no caso dos autos, tenho de ser o caso de se determinar o perdimento do veículo apreendido (fls. 16/17). Como se viu, o automóvel era utilizado para o transporte das drogas, estando devidamente preparado para o exercício do comércio criminoso, a demonstrar o nexo de causalidade entre o delito e o objeto utilizado para sua prática.

DOSIMETRIA:

Em relação ao acusado ROBERT:

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal.

O acusado não é possuidor de antecedentes criminais. E isso porque, não havendo condenação definitiva, tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer:

"(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado" (STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13/08/09).

Nesse sentido, aliás, é a Súmula 444 do STJ.

Sobre a conduta social do acusado e sua personalidade não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos são próprios à espécie.

Já as circunstâncias devem ser consideradas extremamente gravosas, tendo em vista a vasta quantidade de droga apreendida (18471,8g de Tetrahydrocannabinol e 876,6g de Cocaína), e as circunstâncias que envolveram o fato (apreensão de veículo destinado ao transporte dos entorpecentes).

Pondere-se que, como já anteriormente mencionado, a quantidade de entorpecente encontrada, não se dá com qualquer traficante de pequeno porte, evidenciando, sobremaneira, um maior envolvimento do réu, na prática delitiva em questão. Ainda, vale a consideração que, o montante de droga encontrada na residência e veículo do réu, se traduz no mercado ilícito em expressiva cifra. Neste sentido:

"(...) na avaliação das circunstâncias legais para a fixação da pena, sem se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade de droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa" (STJ, Rel. José Arnaldo da Fonseca, HC 18940/RJ). Motivos pelos quais, exaspero a pena-base no dobro.

As consequências do crime foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias judiciais, aplico a pena-base ao réu em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06.

Ausentes quaisquer agravantes. Presentes a atenuante de menoridade, ex vi no inc. I do art. 65 do Código Penal, atenuo a pena até seu patamar mínimo.

Ausentes quaisquer causas de aumento e de diminuição, inclusive a prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Considerando a expressiva quantia de entorpecente apreendida, deixo de operar a diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. É que tais circunstâncias revelam séria incursão da parte acusada na criminalidade, inculcando neste Juízo seja ela dedicada à atividades criminosas

Não é preciso dizer muito para se compreender que a aquisição de tamanha quantidade de entorpecente não se dá com qualquer indivíduo, notadamente com o pequeno traficante. A perda da droga enseja inegável prejuízo, razão pela qual, no mundo do crime, exige-se responsabilidade de quem a transporta. Assim, se logrou a parte acusada assim agir, é porque está inserida na senda delitativa, não fazendo jus, portanto, à redução reclamada pela defesa. A este respeito, observo que:

"o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas" (STJ; HC 163495/SP; Rel. Min. Laurita Vaz; DJe 19/10/2011).

E nem se argumente por bis in idem em relação à quantidade da droga observada na exasperação da base, porquanto, nesta etapa, tal circunstância não é tomada como critério próprio para obstar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, mas, sim, como elemento de convicção que se sintetiza a outros extraídos dos autos e sustentam, afirmativamente, o entendimento de dedicação à atividade criminosa, este, sim, por lei, critério próprio impeditivo do privilégio.

Acerca do entendimento, confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

"2. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. (...) 5. Não configura bis in idem caso, além da quantidade de drogas, haja outros elementos concretos nos autos, suficientes o bastante - tais como apetrechos destinados à traficância, anotações sobre contabilidade do tráfico, munições, armas de fogo, processos em andamento etc. -, que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa. (...)" (HC 373.523/SP; Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz; Sexta Turma; julgado em 14/08/2018; DJe 21/08/2018)

E ainda:

"EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO QUE EXCLUIU A INCIDÊNCIA DA REDUTORA DISPOSTA NO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS. Na hipótese retratada nos autos, verificou-se que o embargante utilizava sua residência como um depósito de grande quantidade de maconha; embora o réu tenha referido que trabalhava em uma lavagem dentro de sua casa, ao realizarem campanhas naquele endereço, os agentes públicos viram pouca movimentação de clientes lavando

seus veículos no local, sendo referido nas informações constantes no incidente do mandado de busca e apreensão que havia movimentação típica de venda de drogas na residência. Ademais, o depósito de 9.430 kg de maconha demonstra relação estreita com traficantes maiores e conhecimento suficiente da logística afeta ao tráfico, possibilitando concluir-se que a prática do injusto penal era contínua e profissional. Inviável, portanto, o reconhecimento da redutora, pois não cumpridos as exigências que a legislação prevê para a aplicação da referida causa de diminuição. DESACOLHERAM OS EMBARGOS INFRINGENTES. POR MAIORIA. (Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70079233383; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais; Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba; Julgado em 05/04/2019).” (TJ-RS - EI: 70079233383 RS; Relator: Rosaura Marques Borba; Data de Julgamento: 05/04/2019; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais; Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/05/2019)

Inexistindo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06.

Considerando que Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da inconstitucionalidade da fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), deve o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, não podendo fundamentar a fixação do regime inicialmente fechado unicamente em relação à hediondez do delito de tráfico de drogas.

A tese restou assim ementada:

“É inconstitucional a fixação ex lege, com base no artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.” (ARE 935.967 AgR; Rel. Min. Edson Fachin; Primeira Turma; J.:15.03.2016)

Desse modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. Vale ressaltar que tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do §3º do art. 33, c.c art. 59 do Código Penal.

Na espécie, considerando o quantum de pena aplicada, bem como a condenação posterior ostentada pelo réu, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §3º, do CP.

Considerando o quantum de pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, prejudicada a análise de eventual concessão de penas restritivas de direito ou, então, a suspensão condicional da reprimenda (artigo 44, inciso III, e artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal).

Em relação ao acusado ANÍZIO:

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada desfavorável. E isso porque, como verificado, para prática delitiva, trouxe o acusado seu filho, com a tenra idade de seis anos, expondo-a aos riscos inerentes daquele que se sujeita a

transportar entorpecentes. Por tal aspecto, exaspero a pena em 1/6.

O acusado é possuidor de antecedentes criminais. E isso porque, conforme se infere da certidão de fls. 89/91, ostenta condenações pelos crimes de receptação (fls. 89/91, 0007181-90.2003.8.26.0505) e extorsão (fl. 89, 0024578-17.2004.8.26.0348), ainda que atingidas pelo período depurador de cinco anos, razão pela qual exaspero a pena em 1/6.

A título de cautela, observo que, firme no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"a legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64, do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior" (RE 901.145-AgR; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJe de 08/11/2018).

Vale dizer, o colendo STF, apreciando o tema 150 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal."

Sobre a conduta social do acusado e sua personalidade não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos são próprios à espécie.

Já as circunstâncias devem ser consideradas extremamente gravosas, tendo em vista a vasta quantidade de droga apreendida (18471,8g de Tetrahydrocannabinol e 876,6g de Cocaína), e as circunstâncias que envolveram o fato (apreensão de veículo destinado ao transporte dos entorpecentes). Pondere-se que, como já anteriormente mencionado, a quantidade de entorpecente encontrada, não se dá com qualquer traficante de pequeno porte, evidenciando, sobremaneira, um maior envolvimento do réu, na prática delitiva em questão. Ainda, vale a consideração que, o montante de droga encontrada na residência e veículo do réu, se traduz no mercado ilícito em expressiva cifra. Por tais motivos pelos quais, exaspero a pena em 1/6:

Neste sentido:

"(...) na avaliação das circunstâncias legais para a fixação da pena, sem se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade de droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa" (STJ, Rel. José Arnaldo da Fonseca, HC 18940/RJ).

As consequências do crime foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias judiciais, aplico a pena-base ao réu em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06.

Ausentes quaisquer agravantes e atenuantes.

Ausentes quaisquer causas de aumento e de diminuição, inclusive a prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Considerando a expressiva quantia de entorpecente

apreendida, deixo de operar a diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. É que tais circunstâncias revelam séria incursão da parte acusada na criminalidade, inculcando neste Juízo seja ela dedicada à atividades criminosas

Não é preciso dizer muito para se compreender que a aquisição de tamanha quantidade de entorpecente não se dá com qualquer indivíduo, notadamente com o pequeno traficante. A perda da droga enseja inegável prejuízo, razão pela qual, no mundo do crime, exige-se responsabilidade de quem a transporta. Assim, se logrou a parte acusada assim agir, é porque está inserida na senda delitiva, não fazendo jus, portanto, à redução reclamada pela defesa. A este respeito, observo que:

"o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas" (STJ; HC 163495/SP; Rel. Min. Laurita Vaz; DJe 19/10/2011).

E nem se argumente por bis in idem em relação à quantidade da droga observada na exasperação da base, porquanto, nesta etapa, tal circunstância não é tomada como critério próprio para obstar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, mas, sim, como elemento de convicção que se sintetiza a outros extraídos dos autos e sustentam, afirmativamente, o entendimento de dedicação à atividade criminosa, este, sim, por lei, critério próprio impeditivo do privilégio.

Acerca do entendimento, confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

"2. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. (...) 5. Não configura bis in idem caso, além da quantidade de drogas, haja outros elementos concretos nos autos, suficientes o bastante - tais como apetrechos destinados à traficância, anotações sobre contabilidade do tráfico, munições, armas de fogo, processos em andamento etc. -, que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa. (...)" (HC 373.523/SP; Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz; Sexta Turma; julgado em 14/08/2018; DJe 21/08/2018)

E ainda:

"EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO QUE EXCLUIU A INCIDÊNCIA DA REDUTORA DISPOSTA NO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS. Na hipótese retratada nos autos, verificou-se que o embargante utilizava sua residência como um depósito de grande quantidade de maconha; embora o réu tenha referido que trabalhava em uma lavagem dentro de sua casa, ao realizarem campanhas naquele endereço, os agentes públicos viram pouca movimentação de clientes lavando seus veículos no local, sendo referido nas informações constantes no incidente do mandado de busca e apreensão que havia movimentação típica de venda de drogas na residência. Ademais, o depósito de 9.430 kg de maconha demonstra relação estreita com traficantes maiores e conhecimento suficiente da logística afeta ao tráfico, possibilitando concluir-se que a prática do injusto penal era contínua e profissional. Inviável, portanto, o reconhecimento da redutora, pois não cumpridos as exigências que a legislação prevê para a aplicação da referida causa de diminuição. DESACOLHERAM OS EMBARGOS INFRINGENTES. POR MAIORIA. (Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70079233383; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais; Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba; Julgado em 05/04/2019)."

(TJ-RS - EI: 70079233383 RS; Relator: Rosaura Marques Borba; Data de Julgamento: 05/04/2019; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais; Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/05/2019)

Inexistindo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06.

Face ao quantum de pena privativa de liberdade aplicada e às péssimas circunstâncias judiciais, deverá esta ser inicialmente cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 33, §3º, do Código Penal).

Considerando o quantum de pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, prejudicada a análise de eventual concessão de penas restritivas de direito ou, então, a suspensão condicional da reprimenda (artigo 44, inciso III, e artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal).

DIANTE DO EXPOSTO:

a) JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado ROBERT DE SOUZA SILVA, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

b) JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado ANÍZIO GOMES DE MACEDO NETO, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Deixo de condenar os réus em custas processuais, dada a hipossuficiência denotada.

Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ante os fundamentos elencados na decisão de fls. 107/110, não reconheço aos acusados o direito de recorrer em liberdade, recomendando-se-o no ergástulo em que se encontra até o trânsito em julgado (art. 387, §1º, c/c art. 312, ambos do CPP).

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada à natureza difusa das vítimas.

DECRETO a perda do veículo apreendido (fls. 16/17, modelo VW/GOL PLUS MI, placas CKC-6417), em favor de entidade beneficente a ser designada oportunamente.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

1. Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
2. Lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal;
3. Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhem-se ao Juízo da Execução, conforme artigo 105 da 7.210/84.

4. VENHAM OS AUTOS CONCLUSOS PARA DESTINAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO (FLS. 13/15);
5. Desde logo, não havendo interesse em recorrer, sai as partes acusadas intimadas para pagamento da pena de multa, bem como da taxa judiciária, se houver, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento a Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o art. 482, §1º, das NSCGJ. Havendo interposição recursal, i-se-a quando do trânsito em julgado.

Publique-se. I-se, devendo os acusados o serem pessoalmente.

Itanhaém, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA